

1500161-93.2022.8.26.0153

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Claudio Sartorelli

Comarca: Cravinhos

Foro: Foro de Cravinhos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... algum tempo, voltou a ser preso por tráfico na mesma praça, que é local conhecido como ponto de tráfico em Cravinhos. O réu já tinha passagens por tráfico desde a adolescência.

A certidão de fls. 102 indica que o réu teve quatro passagens por tráfico de drogas no período de 2020 a 2022, e a certidão de fls. 103 indica que o réu voltou a ser preso na praça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cravinhos

Foro de Cravinhos

1ª Vara

Avenida Fagundes, 29, Cravinhos-SP - cep 14140-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500161-93.2022.8.26.0153 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500161-93.2022.8.26.0153

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2106075/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 24383018 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2106075 - DEL.POL.CRAVINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELYTON DE FREITAS BERTONCINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli

Vistos.

I- Relatório

WELYTON DE FREITAS BERTONCINI está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 14 de abril de 2022, por volta das 18h50min, na Rua Nicola Paciuli, nº 256, nesta cidade e comarca de Cravinhos, WELYTON DE FREITAS BERTONCINI, qualificado às fls. 05, trazia consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 50g (cinquenta gramas) de cocaína e 22g (vinte e dois gramas) de derivados canabinólicos, Cannabissativa, L, substância popularmente conhecida como "maconha", acondicionados em, respectivamente, 62 (sessenta e dois) eppendorfs de cocaína e 12 (doze) trouxinhas de maconha, conforme auto de exibição/apreensão

(fls. 12/13) e laudo de constatação (fls. 15/16), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, os policiais militares estavam em patrulhamento próximo ao local dos fatos, quando avistaram o réu sentado em um banco na praça. Ao divisar a viatura, WELYTON levantou do banco de imediato e os policiais procederam à abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontrados na cintura, por dentro da bermuda do réu, 62 (sessenta e dois) eppendorfs de cocaína e 12 (doze) trouxinhas de maconha. Ademais, ainda, em poder do réu, foi localizada da quantia de R\$ 31,00 (trinta e um reais). Indagado no momento da abordagem, WELYTON afirmou que o entorpecente era de sua propriedade e estaria exercendo a traficância naquele local. Conduzido ao Distrito Policial, durante interrogatório em solo policial, afirmou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder (fls. 05). A quantidade de drogas encontradas, assim como o seu acondicionamento indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 78/79), sendo recebida a denúncia (fls. 86/87). Na fase instrutória foram ouvidas duas testemunhas de acusação, procedendo-se ao interrogatório (fls. 118). Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, sustentando provada a imputação, ao passo que a defesa sustentou que as provas são insuficientes para a condenação.

II - Fundamentação

A ação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/10), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), imagens (fls. 21, 23 e 28), laudo de constatação (fls. 15/16), exame químico-toxicológico (fls. 129/130) e pela prova testemunhal colhida durante a instrução.

O exame químico toxicológico (fls. 129/130) constatou a presença dos compostos químicos METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) e TETRAHIDROCANABINOL (THC) nas substâncias apreendidas com o réu (fls. 12/13) comprovando a materialidade do fato, sendo que as citadas substâncias estão relacionadas na Lista F da Portaria nº 344, de 15/05/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como droga entorpecente e de uso proscrito no Brasil.

Interrogado por ocasião do flagrante (fls. 5), o réu sustentou que foi abordado pelos policiais militares e nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Em juízo relatou que tem passagens enquanto menor por tráfico de drogas, mas não foi internado na Fundação Casa. Confessou que estava sentado no banco da praça e trazia consigo a cocaína e a maconha. Estava no local para realizar o tráfico de drogas.

A confissão foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Edvandro e Yago.

Ambos relataram que estavam no patrulhamento e avistaram o réu sentado em um banco da praça Nova Cravinhos, local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao avistar a viatura policial o réu se levantou e vieram a abordá-lo. Na busca pessoal, na cintura do réu, dentro da bermuda, havia 62 eppendorfs de cocaína e 12 trouxinhas de maconha. No bolso da bermuda havia trinta e um reais em dinheiro e um aparelho celular. O réu confirmou que estava realizando o tráfico no local e foi encaminhado para a delegacia. Edvandro acrescentou que enquanto adolescente encaminhou o réu para a delegacia três ou quatro vezes por tráfico de drogas. Ele foi preso e posteriormente colocado em liberdade na audiência de custódia, sendo que depois de dois meses Welyton foi preso no mesmo local também por tráfico de drogas.

Yago também acrescentou que o réu tentou se evadir da praça em direção à sua residência que fica próxima do local, mas foi contido. Havia um volume na cintura do réu que constatou-se ser uma sacola com cocaína e maconha. O dinheiro estava no bolso traseiro da bermuda. O réu foi preso e colocado em liberdade e, passado algum tempo, voltou a ser preso por tráfico na mesma praça, que é local conhecido como ponto de tráfico em Cravinhos. O réu já tinha passagens por tráfico desde a adolescência.

A certidão de fls. 102 indica que o réu teve quatro passagens por tráfico de drogas no período de 2020 a 2022, e a certidão de fls. 103 indica que o réu voltou a ser

preso na praça Nova Cravinhos em 21.06.2022, corroborando o alegado pelos policiais militares.

A maconha e a cocaína apreendidas com o réu estavam fracionadas e prontas para entrega a consumo de usuários, anotando-se que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo o réu admitido que estava no local para realizar o tráfico e o dinheiro apreendido era proveniente da venda das drogas.

As provas são robustas e autorizam a condenação.

No caso vertente não há qualquer prova de que o réu Welyton sofresse perseguição pelos policiais militares Edvandro e Yago em razão de seus antecedentes.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais possui inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, foi coerente e harmônico, merecendo credibilidade deste juízo. Vale destacar que a Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Não havia denúncias feitas pelo réu contra policiais ou desafetos, a ponto de forjarem uma prisão em flagrante em seu desfavor. Ao contrário, presume-se a idoneidade das testemunhas, servidores públicos que atuam no combate à criminalidade, e não o contrário. Por isso, não há por que duvidar das palavras dos policiais.

Não estavam impedidos de depor. Antes, deviam mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos, como se extrai do art. 6º, III, do Código de Processo Penal. A só condição de funcionários públicos não os torna suspeitos. Seus depoimentos são colhidos mediante o compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em conjunto com as demais provas.

Nesse sentido: "São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos..." (Relator Desembargador ANTONIO LUIZ PIRES NETO, Apelação Criminal nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito.

Nesse sentido há precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 87.662/PE, Relator Ministro CARLOS AYRES BRITO, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJU 18.10.96; HC 70.237, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, RTJ 157/94) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 262.655/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Relator Ministro JORGE MUSSI, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 27.04.10)". (HC nº 356901/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Data da Publicação 22/08/2016).

Ademais, a jurisprudência do STF e STJ já pacificou o entendimento de que não é nula a condenação amparada apenas no depoimento de policiais, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Neste sentido:

"Habeas corpus. 2. Paciente condenado como incurso no art. 12, da Lei nº 6.368, de 1976, a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 50 dias-multa. 3. Alegação de réu ter sido condenado com base exclusiva em depoimento policial. 4. Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes. 5. Habeas Corpus indeferido." (HC 77.565/SP, 2ª Turma, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 02/02/2001.)

"PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido." (HC 76.557/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 02/02/2001.)

"CRIMINAL. HC. CONDENAÇÃO EM PORTE ILEGAL DE ARMAS E USO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO

FÁTICOPROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que ao paciente foram impostas penas pelas práticas dos delitos de porte ilegal de arma e uso de substância entorpecente, sendo, em sede de apelação ministerial, condenado por tráfico de drogas. II. O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte. III. Maiores incursões a respeito das provas que embasaram a condenação do réu não podem ser feitas na via eleita. IV. Ordem denegada." (HC 40.162/MS, 5ª Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 28/03/2005.)

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, CAPUT, C/C O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 6.368/76. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. I - Não há falar em constrangimento ilegal por falta de fundamentação, na medida em que a condenação encontra-se devidamente motivada, com apoio no acervo probatório colhido na instrução criminal. (Precedentes). II - Em nosso sistema, não há, de regra, vedação ao depoimento de policiais. (Precedentes). III - Não se acolhe de writ que, concretamente, quanto à almejada absolvição, pretende o minucioso cotejo do material cognitivo. (Precedentes). Habeas corpus denegado." (HC 34.881/SP, 5ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 03/11/2004.)

"Ademais, a jurisprudência desta Colenda Corte, em perfeita consonância com a do Excelso Pretório, já pacificou o entendimento de que não é nula a condenação amparada apenas no depoimento de policiais, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória." É óbvio que mais correto é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4 - "Cuidando-se de crime de natureza permanente, a prisão do traficante, em sua residência, durante o período noturno, não constitui prova ilícita. Desnecessidade de prévio mandado de busca e apreensão." (STF - HC 84772, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 12-11-2004 PP-00041 EMENT VOL-02172-02 PP-00336 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 474-476)

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (H.C. nº 74.608-0/SP Relator Ministro Celso de Mello).

Saliente-se, ademais, que o crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda.

Nesse sentido: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o

local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT 584/347).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase, a pena base é fixada um sexto (1/6) acima do mínimo legal em razão da alta periculosidade da conduta do réu ao praticar crime de extrema gravidade na atualidade, no caso o tráfico de drogas, bem como pela diversidade e grande quantidade de drogas apreendidas e sendo altamente lesiva a natureza da droga (cocaína), ou seja, cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.

Na segunda fase, as atenuantes da confissão e menoridade reduzem a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, incabível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu não tem bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas. Segundo posicionamento pacífico do STJ: A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. STJ. 5ª Turma. HC 355.593/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/8/2016.

Conforme se observa da certidão de fls. 102, enquanto menor o réu teve quatro atos infracionais relativos ao tráfico de drogas. Os atos infracionais foram praticados em 2020, 2021 e 2022, tendo o réu atingido a maioridade em 27.2.2022. Preso no dia 18 de abril de 2022 na praça Nova Cravinhos, foi colocado em liberdade na audiência de custódia realizada no dia 20 de abril. Em 21 de junho de 2022 novamente foi preso por tráfico de drogas na mesma praça com 23 eppendorfs de cocaína, 17 porções de cocaína e 22 papelotes de maconha.

Não há dúvida de que o réu se dedica a atividades criminosas, tendo ele admitido ter respondido a atos infracionais por tráfico de drogas e, atingindo a maioridade, preso duas vezes em flagrante por tráfico de drogas, não exercendo atividade remunerada, dedicando-se exclusivamente ao tráfico de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça entende que os atos infracionais anteriores, na dosimetria da pena, não podem ser sopesados na apuração de Maus Antecedentes para elevar a pena-base. Entretanto, tais atos infracionais, afastam a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. REGIME ABERTO. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto a consideração de atos infracionais anteriores na dosimetria da pena, esta Corte é uníssona no sentido de que não podem ser sopesados na apuração de Maus Antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência. Entretanto, este Tribunal tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas, sendo inclusive, fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. III - Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de

tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas. IV – Quanto ao regime prisional, a quantidade de entorpecente apreendido, foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V – Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL COMETIDO. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do recorrente ter praticado ato infracional quando adolescente é elemento hábil a afastar o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, se evidenciada a dedicação a atividades criminosas. Precedentes da Quinta Turma. 2. Entender de forma diversa demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial a teor do verbete n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1653501/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma do STJ, data do julgamento 09/05/2017, data da Publicação DJe 17/05/2017).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. 1. Diz o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o paciente seja primário, portador de bons antecedentes, não integre organização criminosa nem se dedique a tais atividades. 2. As instâncias ordinárias afastaram, fundamentadamente, a incidência da benesse pretendida sob o fundamento de que as circunstâncias que ladearam a prática delitiva evidenciam a dedicação do paciente à atividade criminosa. 3. Destacou a sentença que o paciente, além de haver sido preso com considerável quantidade de cocaína - 35 (trinta e cinco) invólucros plásticos - em conhecido ponto de venda de entorpecentes, fazia "do crime seu meio de vida", não comprovando o exercício de qualquer atividade lícita e já ostentando registro anterior na Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado a tráfico de drogas. 4. Indeferida a aplicação do redutor de pena com base em motivação idônea, inviável se torna, na via do writ, o revolvimento de provas com o fim de verificar a justiça da decisão. 5. O regime semiaberto é o recomendável, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o paciente é primário, e a reprimenda não ultrapassa o patamar de oito anos (Súmula nº 440 do STJ). 6. Ordem parcialmente concedida (HC 212704/SP, relator Ministro OG FERNANDES, 5ª Turma do STJ, data do julgamento 15/09/2011 e data da publicação DJe 28/09/2011).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 3. Esta Corte é uníssona no sentido de que atos infracionais anteriores não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência,

entretanto, tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas. Precedentes. 4. Desde que devidamente comprovado, o envolvimento reiterado do paciente, quando menor, em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas. 5. Concluído pela Corte a quo, com fulcro nos elementos colhidos na instrução, que o paciente se dedica a atividades criminosas, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Na definição do regime prisional aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, o julgador deve observar os critérios estabelecidos nos arts. 33 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006. 7. Fixada a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP. 8. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de, confirmando a liminar parcialmente deferida, fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. (HC 299673/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma do STJ, data do julgamento 10/08/2016 e data da publicação DJe 24/8/2016)

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. NARCOTRÁFICO. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos "servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza" e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício. 2. Ordem denegada. (HC 121509/SP, relator Ministro FELIX FISHER, 5ª Turma do STJ, data do julgamento 18/02/2010 e data da publicação DJe 29/3/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Rever o entendimento externado pela Corte de origem para o fim de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Ademais, consta dos autos que o paciente cometeu atos infracionais enquanto adolescente, o que também constitui óbice à incidência do redutor, na medida em que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas (AgRg no REsp 1.816.895/DF, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Quinta Turma, DJe 11/10/2019). 2. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso. Hipótese em que as instâncias ordinárias fixaram o regime prisional mais gravoso com lastro na natureza especialmente deletéria da droga apreendida – 100 eppendorfs de cocaína –, sopesada na primeira fase da dosimetria, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 580.797 - SP (2020/0111354-3) RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA).

TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. ...

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. ... (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 573.149 - SP (2020/0086724-9) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS)

Torno definitiva a pena em totalizando cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.

III – Dispositivo

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de condenar WELYTON DE FREITAS BERTONCINI, qualificado nos autos, à pena de cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa com valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ante a quantidade da pena imposta a Welyton, a alta periculosidade da conduta do réu ao praticar crime de extrema gravidade na atualidade, no caso o tráfico de drogas, e a potencialidade lesiva maior à saúde da cocaína, fixo o regime FECHADO para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Como bem ressaltou o relator Edison Brandão, na apelação criminal nº 0007608-79.2012: “Cumpra observar que o ilícito do qual ora se trata tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Daí o reconhecimento da alta periculosidade da conduta, de forma que o regime fechado permitirá ao condenado uma maior recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto social e a gravidade de sua conduta.”

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03.

Em observância ao disposto no art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial autorizando a incineração da droga apreendida nestes autos. Declaro a perda em favor da União da importância em dinheiro apreendida.

No caso vertente houve por parte do réu descumprimento de uma das medidas cautelares impostas para concessão da liberdade provisória. Conforme se observa da decisão de fls. 46 entre as duas medidas cautelares aplicadas ao réu estava a “proibição de frequentar o local onde se deram os fatos” (letra b). Nos presentes autos o réu estava realizando o tráfico de drogas na Praça Nova Cravinhos (Rua Nicola Paciuli, 256). Segundo os depoimentos dos policiais militares, o réu voltar a ser preso no mesmo local, o que restou corroborado pela certidão de fls. 103, tendo o réu sido preso em 21.6.2022 na mesma Praça Nova Cravinhos (Rua Nicola Paciuli, 256 – processo nº 1501496-83.2022.8.26.0530).

Revogo a liberdade provisória concedida na decisão de fls. 45/47 e decreto a prisão preventiva do réu. No caso vertente há necessidade da prisão do réu a fim de resguardar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa e resgatando a estabilidade social diante da gravidade que representa, nos dias atuais, o tráfico de drogas, crime que impulsiona os delitos contra o patrimônio e os praticados com violência contra a pessoa. Torna-se necessária a prisão como garantia da ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal. Expeça-se o competente mandado de prisão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o Cartório Eleitoral.

P.R.I.C.

Cravinhos, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA